

1502448-75.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2337982/2021 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 21912508 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2337982 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Gustavo Luiz de Souza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502448-75.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001814

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2337982/2021 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 21912508 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2337982 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Gustavo Luiz de Souza Sérvulo

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

GUSTAVO LUIZ DE SOUZA SÉRVULO, qualificado a fls. 05 e 19, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 07h05, na Rua Serra da Mangabeira, n.º 158, casa 02, bairro Campanário, nesta cidade e comarca de Diadema, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 2 (duas) porções maiores e outras diversas pequenas da droga cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 857,2 gramas, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo de constatação de fls. 15/18.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.41/43), o réu foi notificado e citado (fls.76/77 e 151), e apresentou defesa preliminar as fls.89/91, através do Defensor Público nomeado. Não sendo hipótese de arquivamento nem de oferta do ANPP ante a gravidade delitiva, a denúncia foi recebida em 06/04/2022 (fl.93).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns arroladas tempestivamente e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína, em que pese a confissão do réu, discordando da redução da pena e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, sem possibilidade de apelo em liberdade.

Já o d. Defensor Público reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão, reduzindo a pena ainda que em patamar menor, e sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl.12, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls.15/18 e 132/134), ambos positivos para a droga cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.02/03), foram designados para participarem de uma operação voltada a combater o tráfico de drogas na região da Cracolândia, tendo sido incumbidos de cumprirem mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos contra o indiciado Gustavo Luiz de Souza Sérvulo, residente à Rua Serra da Mangabeira nº 168, casa 2, bairro Campanário, Diadema, São Paulo. Ao chegarem no local foram atendidos pela genitora do indiciado, Senhora Marilene, a qual tomou ciência de que existia uma ordem judicial para que fosse vistoriada sua casa, motivo pelo qual permitiu a entrada ao imóvel e esclareceu que seu filho estava dormindo no quarto, onde Gustavo foi acordado e também tomou ciência de que existia ordem de busca para a casa e de prisão contra ele, tendo, contudo, alegado que não tinha nada de ilícito no quarto. Entretanto, dentro de uma caixa de papelão que estava ao lado de sua cama, foram encontradas duas pedras de crack embaladas em plástico, e debaixo de sua cama, ainda foram encontradas duas balanças de precisão e um saco contendo diversas pedras de crack de vários tamanhos, sendo que ao ser indagado acerca de tais fatos, o indiciado disse que não tinha nada a dizer, motivo pelo qual, recebeu voz de prisão.

Sob o crivo do contraditório o policial Carlos Eduardo da Silva confirmou ter cumprido o mandado de busca. Foram em duas viaturas até o local onde o dono os recebeu e indicou o imóvel alugado pelo réu, cuja mãe os recebeu e no quarto onde ele dormia, foi encontrada uma quantidade de droga e embaixo da cama localizaram uma porção maior de droga e a balança de precisão. A mãe dele disse que não sabia de nada porque ele não a deixava entrar no quarto. Reconhece o réu, e ele confirmou

que a droga era dele, e a investigação era ligada à venda de drogas na Cracolândia, em São Paulo.

Igualmente o policial Ernane Ruiz narrou ter ido na casa do réu dar cabo ao mandado de busca e apreensão. A mãe dele permitiu a entrada e o réu estava no quarto dele, dormindo. Na cabeceira da cama tinha uma pequena quantidade de droga e embaixo da cama duas pedras grandes, tudo de aproximadamente um quilo. Ele confessou que era dele. O quarto era do réu e só ele o usava. A residência era um local humilde.

A Sra. Marilene de Jesus, genitora do réu, em solo policial (fl.04) alegou que recepcionou policiais em sua casa pela manhã, os quais lhes informaram que seu filho era alvo de uma investigação e por isso existia mandado de busca para sua casa e de prisão para seu filho. Permitiu que os policiais entrassem no imóvel, sendo Gustavo detido no quarto dele, enquanto dormia, e neste local, os policiais encontraram drogas e algumas balanças, do que a depoente não tinha conhecimento. Vem notando um comportamento suspeito de seu filho, o qual não lhe permite mais entrar no quarto dele nem para limpar, alegando que ali é sua intimidade. Que para evitar discussões a depoente respeita esse espaço de seu filho e chegou a lhe perguntar várias vezes se ele estava fazendo algo de errado, o que ele logo dizia apenas que não e se trancava no quarto. Trabalha como cozinheira numa pizzaria e nunca imaginou que seu filho guardasse drogas em casa, pois chega tarde do trabalho e logo que acorda faz almoço e sai para trabalhar de novo. Na delegacia viu fotos de seu filho vendendo pedras de crack nas barracas da Cracolândia e se diz muito entristecida com toda a situação mas nada sabe dizer que possa auxiliar nas investigações.

Sob o crivo do contraditório essa informante confirmou que os policiais chamaram no portão com documento de ordem de busca. Eles entraram na sua casa procurando seu filho Gustavo que estava no quarto dele. Os policiais encontraram no quarto dele entorpecente na forma de crack e uma balança de precisão. O réu não teve muito o que falar porque foi flagrante. Não sabia de nada porque ele tem o quarto dele e não entrava na privacidade do quarto dele e se viam pouco porque trabalha muito. O réu sempre trabalhou. E desconhece que ele usasse droga. Não entende como seu filho entrou nisso.

O réu, em solo policial (fl.05) tomou ciência de que teve sua prisão decretada por ter sido identificado como sendo um dos traficantes que atua na região da Cracolândia, motivo pelo qual foi feita uma busca em sua casa na manhã de hoje, onde os policiais encontraram drogas e balanças de precisão que estavam em seu quarto, sendo que em relação a estes fatos, o interrogado manifesta o desejo de permanecer em silêncio. Que sua mãe não sabia que o interrogado tinha drogas em sua casa.

Em juízo o acusado assumiu e confessou que foi ele mesmo. Que sempre trabalhou desde os doze anos de idade, e não sabe o que aconteceu de uns anos pra cá, depois que levaram sua moto e perdeu o trabalho na pizzaria. Sua namorada disse que tinha a tirado de casa, com criança pequena, para passar dificuldade, e então foi traficar. Confirma que tinha duas pedras grandes de crack e outras menores, oitocentos e cinquenta gramas ao todo. Vendia a droga na Cracolândia. Não foi processado antes e está arrependido.

Logo, a confissão judicial, que não é prova única até porque veio confirmada pelos testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, até porque a própria mãe do acusado confirmou que os policiais, cumprindo mandado de busca e apreensão, localizaram no quarto do réu a droga e uma balança de precisão.

Ainda assim não fosse, tem-se o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

Como visto, os policiais sempre afirmara que o réu, por eles reconhecido, foi o indivíduo identificado por diligências anteriores como sendo um dos traficantes que atuam na Cracolândia, e com mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão, localizaram na cabeceira da cama dele e embaixo da mesma cama onde ele dormia, pedras maiores e menores de crack e balança de precisão, o que foi acompanhado pela mãe do réu, quem assim o confirmou em juízo, e nesse sentido foi a confissão judicial do réu. Assim, a suspeita verificou-se verídica.

Ainda que não presenciado, no dia da prisão, ato de comércio, mas sim por vídeo que gravou o réu vendendo drogas na Cracolândia em data anterior, tem-se que as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares de guardar e manter em depósito, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Afasto tese de estado de necessidade ou de situação de pobreza, até por ausência de prova nesse sentido trazida pela Defesa, além dos bens jurídicos serem desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, tratando-se ainda, de crime de perigo abstrato. Assim, o argumento de que o réu praticou o crime em razão de precariedade financeira não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, tampouco de reduzir a sua pena. Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão. Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Ao contrário: buscam solução para seus problemas financeiros através de trabalho honesto. Assim como desemprego não é causa excludente de ilicitude, sob pena de se legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que estivesse desempregado e em precárias condições econômicas - o que não é aceitável.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaína na forma de pedras de crack), a quantidade de narcóticos (857,02 gr.), a prévia denúncia contra o réu que culminou com a expedição de mandado de prisão e mandado de busca e apreensão, são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerado o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, que determina a preponderância da alta quantidade da substância, exaspero as penas base tendo em conta os 857,02 gramas de crack apreendidos, restando fixado o acréscimo de 1/6 na pena, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Em segunda fase, ausente circunstâncias agravantes. Mas presente circunstância atenuante da confissão judicial, e como também me valí dessa prova a embasar a condenação, ante a colaboração do réu com a busca da verdade real, por questão de justiça, acolho tal circunstância a reduzir a pena ao mínimo legal, que nesta etapa cai para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio

previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, embora se trate de réu primário (fl. 35/37) mas por outro lado, considerando a natureza da droga, crack, sua maior capacidade de alcançar e viciar facilmente um enorme número de pessoas, quanto mais os que já estão em situação de rua, na Cracolândia, uma verdadeira feira como dito pelo réu, que mais disseminou e contribuiu para o vício de pessoas que deveriam estar sendo tratadas e acolhidas, e não mantidas no vício para sustentarem economicamente o réu e sua família, onde se vê a maior reprovabilidade da conduta. Ademais, o crack, como já dito, é o câncer da sociedade, por se tratar de entorpecente de alto poder lesivo à saúde humana, altamente viciante e degradante para a sociedade. E diante do mandado de busca e apreensão concedido face à investigação prévia que indicou o réu como sendo um dos vendedores de crack na feira da Cracolândia, somado ao encontro de balança de precisão usada para dividir as pedras e pesá-las para venda individual, indicativos de maior dedicação ao acusado ao crime, que segundo sua própria confissão, vendia na feira, o que demonstra também integrar organização criminosa estabelecida, entendendo incabível o redutor, por estar o agente fazendo do tráfico ilícito de narcótico o seu meio de vida como ele mesmo disse, para seu sustento e da família, portanto inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal.

Inclusive, nesse sentido é a jurisprudência que menciono: Quantidade de drogas, por si só, basta para modular redutor de pena, diz STJ -07/10/2021 - É possível a valoração isolada da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 - neste último caso, assim, ainda que sejam os únicos elementos aferidos. Processo nº HC 685.184.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena maior que os 04 anos máximos permitidos) além de não se mostrar socialmente recomendável, dado que insuficiente e ineficaz à reprovação da grave conduta e à recuperação do agente. Ademais: "Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime." (TJAP) RT 772/617.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, fixo o regime prisional fechado, dada à preponderância da natureza e da quantidade da droga, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional." (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas já que filmado vendendo drogas na Cracolândia desde dias antes de sua prisão, bem como constatada ausência de vínculos firmes por estar desempregado, como confessou. Ademais: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de seis meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra GUSTAVO LUIZ DE SOUZA SÉRVULO, qualificado a fls. 05 e 19, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e o faço para condená-lo à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 500 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de objetos apreendidos (fl.12), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA